

1500843-28.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500843-28.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500843-28.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública e outro

Indiciado:

MARIO FABIAN CRISTALDO GONZALEZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MARIO FABIAN CRISTALDO GONZALEZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de junho de 2021, por volta das 17h50min, na "Rodovia Assis Chateaubriand", município de Guapiaçu, nesta comarca, trazia com ele e transportava, entre unidades federativas, para futura entrega a terceiros, trinta e oito tijolos de "maconha", pesando, aproximadamente, 1197 kg, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portava, ainda, o réu, um aparelho celular "Samsung".

Policiais civis, com informações de populares sobre o transporte da droga, abordaram o réu na condução do caminhão "IMP/Scania", placas BET-156/Paraguay, com semirreboque, localizando-se, em revista pessoal, o celular, bem como, escondidas entre a carga, as porções do entorpecente, pelo denunciado transportadas do município de Foz do Iguaçu/PR, com destino a Araguari/MG.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

Não há nos autos prova inequívoca de transnacionalidade da droga apreendida, de modo a se fixar a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109 da Constituição Federal.

Apesar de residir o réu em outro país, admitiu, em Juízo, ter sido carregado o veículo, com a substância ilícita, no Estado do Paraná, para transporte entre Estados da Federação.

Assim, afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio dos autos de exibição e apreensão de fls. 10/11 e 69/70, a revelar o encontro da droga, do veículo e do celular em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 21/23 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 66/68, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahidrocannabinol - THC, a substância encontrada.

O aparelho celular foi vistoriado, constatando-se diálogos relativos ao comércio ilícito (fls. 85/91).

Na fase administrativa exerceu o réu a prerrogativa constitucional de permanecer calado.

Em Juízo, confessou o réu ter transportado, em caminhão, a "maconha", em meio a arroz, sendo que receberia R\$ 35.000,00, no destino. Não identificou o réu com quem teria negociado.

Segundo policiais, informações anônimas propiciaram a abordagem ao réu, enquanto trafegava com o caminhão, ocasião na qual localizaram, em revista pessoal, o aparelho celular. Continuam no sentido de que, em revista ao compartimento de cargas do caminhão, encontraram os tijolos do entorpecente, tendo admitido o denunciado, cuja nacionalidade é paraguaia, a contratação para o transporte do tóxico do município de Foz do Iguaçu até Araguari, sendo que receberia R\$ 35.000,00, pela prestação deste serviço.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais incriminar o réu ou forjar o crime. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Importante consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, sendo o transporte do entorpecente, com intuito de auferir rendimentos, medida impositiva

na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação, pelos elementos que cercam o agente, da prática de um dos verbos nucleares do tipo penal. Confira-se: "(...) o crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes." (STJ, REsp 1.384.292/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10/03/2020).

A unanimidade da prova revelou, por fim, a ocorrência da causa de aumento da pena relativa ao fato de ter o réu transportado o tóxico entre Estados da Federação. Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas. Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da elevada quantidade de tóxico em transporte.

Verificada a confissão da autoria, incide a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, razão pela qual reduz a pena em $\frac{1}{6}$ (um sexto), o que perfaz 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico aconteceu entre Estados da Federação, elevo a pena em $\frac{1}{3}$ (um terço), o que perfaz 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da

sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a quantidade da droga apreendida indica dedicar-se o réu à atividades criminosas, já que ausente comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A elevada quantidade de drogas apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. 3. A despeito de, no julgamento do REsp n. 1.773.834/ES, a Sexta Turma ter ressaltado que a diretriz fixada comporta prova em sentido contrário, no caso, a Defesa não se desincumbiu desse ônus, pois não há qualquer indicação nos autos que afaste a responsabilidade do Acusado acerca da apreensão de 41,820kg de cocaína e 10,240kg de pasta base do mesmo entorpecente. 4. O redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base não apenas na quantidade de droga apreendida e na forma de acondicionamento, pois as instâncias ordinárias também mencionaram outras circunstâncias do caso concreto aptas a justificar a não concessão da citada benesse e a confirmar que a conduta praticada pelo Réu não é algo casual e isolado, quais sejam; "transporte de droga típico de uma organização com vínculo internacional poderosa, a qual contou com uma teia de colaboradores, sendo importante destacar que o plano arquitetado foi muito bem elaborado e esse tipo de negociação certamente envolve diversas pessoas, e não apenas o transportador da cocaína, nem tampouco o funileiro que a escondeu no veículo, mas também capitalizados compradores e fornecedores." (STJ, AgRg no AREsp 1799093/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021) O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MARIO FABIAN CRISTALDO GONZALEZ, R.G. n.º 5.284.064, a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do caminhão e do semirreboque (fls. 10/11), porque utilizado como instrumento do crime, bem como do celular, pois obtido em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA